

1500193-14.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500193-14.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500193-14.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083317/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 23872995 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2083317 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOEL LULU DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu JOEL LULU DOS SANTOS como incurso nos art. 33, "caput", e no art. 35, "caput", da Lei Federal no 11.343/06, ambos c.c. o art. 40, inciso VI (adolescente), da Lei Federal no 11.343/06, na forma do art. 69 (concurso material), do Código Penal porque, em tese, dia e local indeterminados, mas até dia 25 de março de 2022, por volta das 21h50min, na Rua Egídio Bianchi, nº 258, Jardim Donalízio, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado associou-se aos adolescentes inimputáveis Igor Lulu dos Santos e Igor Carlini, com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei Federal no 11.343/06. Consta, ainda, que no dia 25 de março de 2022, por volta das 21h50min, na Rua

Egídio Bianchi, nº 258, Jardim Donalizio, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o réu agindo em concurso com os adolescentes inimputáveis Igor Lulu dos Santos e Iago Carlini, previamente associados e em unidade de desígnios, guardavam e traziam consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 71 (setenta e uma) porções de "cocaína", com peso líquido de 43,46g (quarenta e três gramas e cinquenta e seis centigramas); b) 05 (cinco) porções de "maconha", com peso líquido de 5,01g (cinco gramas e um centigramas) e c) 04 (quatro) porções de "crack", com peso líquido de 0,70g (setenta centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 26 de abril de 2022. (fls. 71-76).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 99-112).

A denúncia foi recebida em 24 de junho de 2022 (fl. 118-119).

Durante a instrução processual foram inquiridas duas testemunhas de arroladas pela acusação e o réu foi interrogado.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, condenando o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com aumento de pena previsto no artigo 40, VI da Lei Federal no 11.343/06, absolvendo-o pelo delito de associação para o tráfico. Com relação a dosimetria da pena, pleiteia a aplicação da pena acima do mínimo legal, afastamento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e regime de cumprimento inicial compatível com a pena aplicada. A Defesa, por seu turno, requereu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 e absolvição pelo crime de associação para o tráfico, formulando pedido subsidiário de reconhecimento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal merece parcial procedência.

Iniciando pela imputação referente à prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a materialidade e autoria delitiva ficaram comprovadas através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08-11), auto de exibição e apreensão (fl. 14-15), auto de constatação preliminar (fl. 16-17), laudo de exame químico toxicológico (fls. 84-87) e laudo dos aparelhos celulares apreendidos (fls. 169-197) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

Os guardas municipais Antônio Alessandro Frois e Thiago Martins, testemunhas de acusação, relataram, em resumo, que estavam em patrulhamento e pelo bairro Santa Lucia, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando ao acessarem a Rua Egídio Bianchi, avistaram três indivíduos parados ao lado de um muro. Joel segurava uma sacola plástico cor de rosa e os menores Iago e Igor retiravam algo do interior da referida sacola. Ao notarem a presença da viatura, Joel soltou a sacola no chão. Igor já havia retirado um embrulho plástico de cor branca de dentro da sacola e tentou empreender fuga mas, foi detido. Os três foram abordados e realizada busca pessoal. O embrulho plástico que estava com Igor continha em seu interior 28 pinos transparentes com cocaína. Com o Joel havia a importância de R\$5,00 (cinco reais) em sua carteira e com Iago Carlini havia R\$64,00 (sessenta e quatro reais) no bolso de sua bermuda. No interior da sacola que Joel soltou, existia um kit contendo 28 pinos transparentes com cocaína, 15 pinos transparentes com cocaína que estavam soltos, 05 porções de maconha e 04 porções de crack.

Indagados, os três mantiveram-se em silêncio. Joel e o irmão Igor já eram conhecido dos meios policiais. Eram vistos em pontos de tráfico de drogas pelo bairro Santa Cruz e Nações. Antonio Alessandro Frois já participou de flagrante envolvendo Joel. Iago foi a primeira abordagem. (íntegra às fls. 206- 220).

O réu Joel Lulu dos Santos interrogado judicialmente, alega que mora no Jardim Imperador, do outro lado da cidade, foi encontrar uma garota no bairro Santo Inácio, parou na Rua Egydio Bianchi para comprar drogas para uso próprio. Estava com R\$15,00 (quinze reais), mas não chegou a comprar a droga. Seu irmão Igor Lulu dos Santos já estava no local. Não conhece Iago Carlini. Os guardas municipais chegaram, fizeram a abordagem e encontraram a sacola de drogas no chão. Não sabe de

onde veio a sacola. Seu irmão Igor estava na companhia de outros dois ou três indivíduos, um correu quando avistou a viatura. Não segurou a sacola com entorpecentes em nenhum momento. Não viu se o irmão ou o outro indivíduo estavam com a sacola nas mãos. Não tem aparelho celular, o irmão sim. Foi a terceira ou quarta vez que o irmão foi detido por envolvimento com tráfico de drogas. Era usuário de cocaína, mas atualmente não faz mais uso. Já foi abordado pelos mesmo guardas municipais. Acredita que foi abordado várias vezes pois o outro irmão está preso por tráfico. Está respondendo um outro processo por tráfico, admite já ter "mexido com essas coisas" (íntegra às fls. 230-241).

Com efeito, os guardas municipais apresentaram versão firme e coerente demonstrando que o réu trazia consigo uma sacola de cor rosa contendo entorpecentes, enquanto os adolescentes Igor Lulu dos Santos e Iago Carlini retiravam algumas porções de drogas do interior dela. Ao notar a aproximação da guarnição, o réu dispensou a sacola e Igor ficou com um "kit" de entorpecente nas mãos. A sacola plástica dispensada foi recuperada, constatando-se que continha quarenta e três porções de "cocaína", cinco de "maconha" e quatro de "crack" e no "kit" recolhido com o adolescente Igor havia outras vinte e oito porções de "cocaína", acondicionadas e prontos para comercialização. Consignaram, ademais, que Joel e o irmão Igor já eram conhecido dos meios policiais e eram vistos em pontos de tráfico de drogas pelo bairro Santa Cruz e Nações, sendo que Antonio Alessandro Frois já participou de flagrante envolvendo Joel.

As declarações de agentes da guarda municipal possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, não possuem, a priori, motivo algum para falsamente incriminar o réu. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

Além disso, cuida-se de crime permanente e, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, considerando, ademais, que a prisão decorreu de abordagem, sem qualquer investigação prévia, de modo que inexistiu óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Cívicas). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021). Não restou provado que o réu fosse inimputável, o mero fato de o acusado ser usuário não impede que ele exerça também a traficância, circunstância aliás que não se mostra incomum, devendo ser observado o artigo 28, inciso II, do Código Penal. Nota-se que o acusado confirma ter ido ao local dos fatos, contudo, tenta se furtar

da responsabilidade argumentando que pretendia encontrar uma garota de nome Daniele e parou para comprar drogas para uso próprio. Não parece crível que, diante dos inúmeros pontos de tráfico, o réu tenha se deslocado até um bairro do outro lado da cidade apenas para adquirir drogas, sendo encontrada em sua carteira tão somente a importância de R\$5,00 (cinco reais). Além disso, a alegação de que iria encontrar uma garota não restou minimamente demonstrada. A respeito do ônus da prova por parte do acusado, esclarece Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal (2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação do alibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime). Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o alibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado."

Acrescento que os invólucros de cocaína recuperadas no interior do embrulho plástico em poder do adolescente Igor eram semelhantes aqueles encontrados na sacola que Joel soltou no chão (vide exame químico toxicológico fls. 84-87). Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, certo é que as circunstâncias da prisão, a variedade e forma de armazenamento das drogas denotam o intuito mercantil e, corroborados pelos depoimentos seguros das testemunhas, são suficientes a embasar o decreto condenatório, afastando, assim, a alegação de porte para consumo próprio.

Cabe aqui enfatizar que a Lei Federal no 11.343/06, art. 40, inciso VI, conferindo uma maior reprovabilidade da ação, prevê aumento de pena para o traficante que, no sentido de atuar conjuntamente, em concurso eventual, utiliza ou conta com a participação de criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.

Nota-se que, de acordo com depoimento do agentes que realizaram a abordagem, é possível concluir que o réu se aproveitou da maior suscetibilidade dos adolescentes Igor e Iago para praticar o tráfico de drogas.

Além disso, o laudo pericial realizado nos aparelhos celulares apreendidos (fls. 169-197) confirma o envolvimento dos adolescentes no tráfico de drogas. É possível verificar no aparelho celular Motorola, modelo XT1962-4, com contas de aplicativos cadastradas em nome de "Iago Carlini" conversas potencialmente relacionadas com a natureza do crime em comento. Dentre elas a realizada por meio do aplicativo "Facebook Messenger", em que usuário do aparelho celular periciado "Iago Carlini" pede ao contato identificado como "João Pedro Tararam" para vender drogas no escadão (local dos fatos segundo depoimento dos guardas municipais fls. 209). "Iago Carlini: Eo Beck tá tendo aí pra vende? João Pedro Tararam: Sim. Crack. Lança chega sábado. Iago Carlini: Demoro amanhã vou encosta aí pega um verde. João Pedro Tararam: Fx. Da slc antes. Iago Carlini:Dmr. Ai deixa eu perguntar tá precisando de ninguém pra trampa no escadão de dia não. João Pedro Tararam: Ss. Iago Carlini: Mas aí que hora se consegue me solta. Tô mas daí lá é so na madrugada cxxr tenho que levantar uma moeda pro pião. Vê aí c der você me dá um salve aqui. [...] João Pedro Tararam: Que trampa já. Iago Carlini: Demorou. João Pedro Tararam: Fx. Cola no escadão. Aki. [...] Iago Carlini: Demorou já vou encosta ai" (fls. 175-179). E ainda, em mensagens trocadas entre o usuário do aparelho celular periciado e o contato identificado como "Alana Magalhães" é possível verificar que Iago Carline se intitula "gerente do tráfico", senão vejamos: "Iago Carlini: Slk ninguém é Loko d relar em mim não. Alana Magalhães: Ah é vc é do crime vdd kkkkkkkk Seu bucaco é mais embaixo. Iago Carlini: kkkkkkkkk isqueceu? Gerente agr kkkkkkk vida boa [...]. Imagem enviada aparentando ser pinos contendo entorpecente (fl. 183) Iago Carlini: Comería crack vida? Alana Magalhães: Um amg meu fuma né ai ele disse que 1 grama tava 15 reais kkkkkkkk. Nunca que eu ia gastar tudo isso. Pqp coisa cara. Iago Carlini: Cmg tá 5 uma grama. Eu tô pegando de kilo [...] Iago Carlini:

Tem 1700 reais de droga aqui [...] kkkkkkkkkkkkkk eu pego mas 10 mil de dinheiro de droga por semana mas não é tudo meu eu sou o gerente que só entrega a droga prós mlk e passo pra receber o dinheiro" (íntegra às fls. 181- 186).

Já no aparelho celular Motorola, modelo XT1603, cuja conta do aplicativo "Facebook Messenger" estava cadastrada em nome de "Igor Lulu", nota-se conversas possivelmente relacionadas a dívidas de usuários de drogas com ele. "Igor Lulu": Bom dia joia. Na paz? Pablo Henrique: Bom dia pá nós. Igor Lulu: O Nicolas tá fechando o quem? Pablo Henrique: Na luta tlgd. Sei não pk. Igor Lulu: Ele me deve uma moeda Slk. Pablo Henrique: Quantos. Igor Lulu: Mó tiração ele. 600. Pq? Pablo Henrique: Tá porra. Igor Lulu: Vai paga Zé. Pra ele. Pablo Henrique: Ele tá fechando aqui no escadão. Igor Lulu: Já conduzi ele já. Pablo Henrique: Encosta que vc pega ele já".(fls.190-191). Por fim, foram observadas imagens de jovens portando cigarro aparentando ser maconha (fls. 195-196).

Nessa lógica, mister o reconhecimento da causa de aumento de pena, em patamar mínimo. No mesmo rumo, o seguinte precedente:

"Apelação. Tráfico de drogas. Acusado flagrado em via pública, juntamente com um adolescente, na posse de 85 porções de cocaína, com peso total de 23g; 59 porções de maconha, pesando 180,1g; 7 frascos de lança-perfume, com volume líquido total de 339 mililitros; e um comprimido de ecstasy, com peso de 0,32g. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Condenação mantida. Redução da pena. Réu primário e de bons antecedentes. Básica fixada no piso. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal, em seu grau máximo. Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do apelante. (TJSP; Apelação Criminal 0006695-78.2018.8.26.0635; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)."

Ressalta-se que o plenário do STF, em julgamento de repercussão geral, firmou o entendimento de que: "PENAL- FIXAÇÃO -ANTECEDENTES CRIMINAIS - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais". (STF RE 591054). O mesmo posicionamento foi cristalizado pelo Enunciado nº 444 da Súmula do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base". Assim sendo, o inadmissível a valoração como maus antecedentes criminais do processo criminal em curso (fls. 35).

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)". Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá.

Na hipótese analisada, a quantidade de droga apreendida é pouco expressiva: 43,46g (quarenta e três gramas e cinquenta e seis centigramas) de cocaína, 5,01g (cinco gramas e um centigramas) de maconha e 0,70g (setenta centigramas) de cocaína na forma petrificada, as ações penais em curso não são considerados como maus

antecedentes ou reincidência, o réu é tecnicamente primário (fls. 35-36) e não restou provado que ele integra organização criminoso, considerando que a prisão decorreu de abordagem de guardas municipais sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo. Salientando-se que, como processos e/ou inquéritos em curso não podem ser considerados na fixação da pena-base, em face do princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art.5º, LVII), pela mesma razão também não se afiguram aptos a obstaculizar a figura privilegiada.

Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO (recurso apenas defensivo) – Tráfico de entorpecente – Pleito da Justiça Gratuita atendido. "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça" (§ 4º do art. 99 do NCPC), anotando-se, porém, na esteira do sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que "A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos" e que "a análise da miserabilidade do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções", até porque pode sobrevir, naquele lustro, "mudança na situação econômica da beneficiária" – No mais, materialidade e autoria delitivas comprovadas – Sem olvido de que "Toda pessoa poderá ser testemunha" (art. 202 do CPP) – , nada foi comprovado em pretório (art. 156 do CPP) que demonstrasse qualquer equívoco, animosidade ou inimizade a retirar a credibilidade da prova testemunhal policial, não se podendo inferir, pois, que houvesse na espécie incriminação sem justo motivo. Seria um contrassenso a sociedade organizada (Estado) arregimentar pessoas para a atividade policial e depois negar-lhes valia no trabalho realizado. Ademais, existe, in casu, testemunha civil também a incriminar a ré – Em casos dessa ordem, onde a traficância imputada não é na modalidade "vender", em nada beneficia a acusada o fato de ela não ter sido avistada contatando outras pessoas e/ou vendendo-lhes o estupefaciente, nem mesmo a circunstância de nenhum tóxico ter sido encontrado em seu poder no momento da abordagem policial, eis que a increpação é de que ela "guardava" e "tinha em depósito" a droga, afigurando-se desnecessário saber, inclusive, de quem era a propriedade respectiva, posto que, onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo – Comprovada a narcotraficância irrogada, impossível a desclassificação para a infração do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – Tráfico Privilegiado (§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006). Cabimento. Como processos e/ou inquéritos em curso não podem ser considerados na fixação da pena-base, em face do princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art.5º, LVII), pela mesma razão também não se afiguram aptos a obstaculizar, ainda no momento dosimétrico (terceira etapa), a figura privilegiada (onde existe a mesma razão, aí há o mesmo direito: ubi eadem ratio ibi idem ius). (STF e STJ) – Indemonstradas circunstâncias outras a obstar a benesse legal, a aplicação de tal redutor legislado deve se dar no máximo legal (2/3), dado que o tóxico apreendido o foi em pequena quantidade (menos de 4 gramas de crack), com regime inicial aberto (diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, da primariedade e do quantitativo sancionatório), como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime no caso concreto (CP, art. 33, §2º, "c", e §3º, c.c. o art. 59, caput, in fine, e III, e com o artigo 42 da Lei de Drogas) – Inconstitucionalidade do valor da pena de multa prevista na Lei Antidrogas – Inocorrência. A Lei nº 11.343/2006 é especial em relação ao Estatuto Repressivo (art. 49), de modo que, com rigores sancionatórios ínsitos à inafastável necessidade de se tutelar a saúde pública, deve prevalecer sobre a regra geral (lex specialis derogat legi generali), sem qualquer inconstitucionalidade, até porque editada pelo Poder Legislativo, a quem cabe, na sua tarefa de satisfação do interesse público, não só definir os tipos penais, mas também estabelecer as respectivas sanções. Toda e qualquer punição estatal advinda de condenação criminal repercute, de uma maneira ou de outra, no ius ambulandi do sentenciado, com inegável reverberação econômica não só à sua pessoa, como também àquelas que dele monetariamente dependam. Mas isso não pode significar, por óbvio, violação à intranscendência subjetiva das sanções, albergada no artigo 5º, XLV, da Constituição da República; as normas

constitucionais não comportam interpretações estanques, devendo coexistir contextualmente, e, assim, também permitir a apenação daqueles que infringirem a normatividade penal posta, como se depreende de vários dos incisos hospedados naquele mesmo artigo 5º. Tem-se, nesse contexto, a busca do primado maior da Justiça, de se dar a cada um o que é seu (*suum cuique tribuere*), inclusive individualizando-se a pena, como expressamente contemplado no citado artigo 5º, desta feita no inciso XLVI, e dessa forma possibilitar o respeito à harmonia e ao bem-estar sociais, consoante o preâmbulo da mesma Lei das Leis - Presentes os requisitos legais, cabível a substituição da pena corporal por duas restritiva de direitos, a teor da segunda parte do § 2º (quantum superior a 1 ano) do artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal. Inviável tal permuta "por multa"; diversamente, se estaria desnaturando a mens legis, que cominou à espécie, cumulativamente, reprimenda prisional e (também) multa, de maneira que a aplicação de uma nova pena de multa não se afigura socialmente recomendável em casos que tais, pois, em última análise, ter-se-ia como resultado somente sanção pecuniária (STJ) - DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1501447-21.2019.8.26.0571; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021)".

De outro lado, com relação ao crime de associação para o tráfico, não há prova suficiente para a condenação do acusado. A associação criminosa é um delito autônomo. Para que alguém responda por este crime são necessários os seguintes elementos: a) duas ou mais pessoas; b) acordo dos parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de traficar tóxicos.

No caso dos autos, não ficou configurado o animus associativo, o dolo, ou seja, a vontade de se associar. A denúncia não narrou o modo nem o momento em que teria se estabelecido o vínculo associativo entre o acusado e os adolescentes. Além disso, reitero que não houve a realização de qualquer procedimento investigativo prévio, nem prova sob a égide do contraditório, que demonstrasse um mínimo de organização e planejamento para a prática da associação criminosa. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, relembro que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição pela prática do delito de associação para o tráfico, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Do contrário, o caso é de mero concurso de pessoas. 3. As instâncias ordinárias embasaram a condenação dos pacientes em elementos fáticos e probatórios concretos - com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais -, os quais, detidamente examinados em primeiro e segundo grau de jurisdição, conduziram à conclusão de que os réus integrariam, de maneira estável e permanente, associação criminosa voltada à comercialização ilícita de entorpecentes. Assim, desconstituir tal entendimento, para absolver os pacientes, implicaria aprofundado reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso dos autos, não é possível a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois a referida benesse não é aplicável a réus também condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, circunstância que denota, necessariamente, a sua dedicação à atividade criminosa. 5. Agravo desprovido. (STJ -

AgRg no HC: 618503 RJ 2020/0267075-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)",

Assim, consoante manifestação do Ministério Público, a absolvição do réu pelo crime de associação ao tráfico é medida que se impõe.

Fixadas tais premissas, passo a dosar a pena, nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é tecnicamente primário (Súmula 444 STJ), culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei Federal no 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Considerando a primariedade, a quantidade de drogas apreendidas, o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa e, tendo em vista que a participação do adolescente, por si só, não indica que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena final de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no mínimo legal.

Diante da quantidade das penas aplicadas, as circunstâncias judiciais favoráveis e, sendo o réu primário, o regime é aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

1) CONDENAR o réu JOEL LULU DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

2) ABSOLVER o réu JOEL LULU DOS SANTOS da prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Faculto a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicados.

Expeça-se alvará de soltura.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 05 de dezembro de 2022.

MARGEM DIREITA